

1500382-12.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... com o reconhecimento do tráfico privilegiado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

Ricardo Alexander de Souza Gonçalves, policial militar, durante patrulhamento em região conhecida de tráfico de drogas avistou o acusado, o qual demonstrou inquietação e nervosismo ao deparar-se com a presença da viatura; abordado, em poder do investigado foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500382-12.2022.8.26.0530 - controle nº 2022/000156

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2040289/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN PATRICK DE OLIVEIRA SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

Vistos.

KAUAN PATRICK DE OLIVEIRA SANTANA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e artigo 12, da Lei 10.826/2003, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, após adquirir de forma escusa, possuía, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares, as seguintes substâncias entorpecentes:

a) 155,38g da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "COCAÍNA", na forma de pó amarelado, em 01 invólucro de plástico de cor branca;

b) 60,05g da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "COCAÍNA", na forma de pó branco, em 02 invólucros de plástico, sendo um na cor branca e outro na cor verde;

- c) 4,39g da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "COCAÍNA", na forma sólida de cor parda, em 01 invólucro de plástico de cor verde;
- d) 12,18g da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "COCAÍNA", na forma de pó branco, em 26 microtubos de plástico, do tipo "eppendorf", de cor preta;
- e) 127,78g da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "MACONHA", na forma de fragmentos vegetais, em 01 invólucro de plástico de cor branca, contendo 05 invólucros plásticos aderentes com fragmentos vegetais e fragmentos vegetais desprovidos de invólucros individuais;
- f) 376,26g da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "MACONHA", na forma de fragmentos vegetais, em 01 invólucro de plástico incolor envolto por fita adesiva parda.

Ainda porque, na mesma data e lugar acima mencionados, o acusado mantinha sob a sua guarda, no interior da residência, 04 cartuchos, de calibre 38, da marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares efetuavam patrulhamento repressivo pelo local dos fatos quando avistaram o acusado e resolveram abordá-lo. Realizada busca pessoal, os agentes localizaram, em poder do acusado, 26 cápsulas plásticas contendo "cocaína" e um telefone celular da marca Samsung.

Informalmente indagado, o acusado teria afirmado que estava produzindo, acondicionando e comercializando drogas, sendo que o restante do entorpecente se encontrava no interior de sua residência.

Diante disso, prosseguindo nas diligências, a equipe policial se deslocou até o imóvel e, após vistoria, encontrou e apreendeu 01 tablete pequeno de "maconha", 06 porções da mesma droga, 01 pedra de "crack", 02 porções ensacadas de "cocaína", 01 sacola contendo "cocaína", 06 frascos contendo líquido com a especificação "cloreto de sódio", 01 máquina de cartão da marca "Moderninha" e a quantia de R\$172,00 em dinheiro, bem como petrechos para o tráfico de drogas consistentes em 01 saco contendo várias cápsulas plásticas vazias, 01 balança de precisão pequena e, ainda, um caderno com anotações sugestivas ao comércio de entorpecentes.

Ademais, os policiais militares apreenderam, no interior da residência, 04 munições de calibre 38 e 01 simulacro de arma de fogo, cujos mecanismos estavam inoperantes. Indagado acerca desses objetos, o acusado relatou que utilizava o simulacro para a prática de roubos.

Dispensada a realização de audiência de custódia, nos termos do Comunicado CG 232/2020 e dos Provimentos CSM 2548/2020 e CSM 2633/2021, todos deste Tribunal de Justiça, e Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional da Justiça, como medida profilática a evitar a disseminação da denominada Covid-19, o acusado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 12 de fevereiro de 2022 (págs. 80/84).

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 22 de fevereiro de 2022 e, na mesma oportunidade, deferida a quebra do sigilo telemático do telefone celular apreendido e da máquina de cartão "Moderninha" (págs. 174/177).

Pessoalmente citado (pág. 205), o acusado apresentou resposta à acusação (págs. 241/242).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, com a ferramenta Microsoft Teams a prova oral foi colhida e interrogado o acusado. Debates realizados, o representante do Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, arguiu nulidade decorrente de prova ilícita, pois teria o acusado sem justa causa sido abordado para depois ainda haver a violação de domicílio pela equipe policial sem autorização quer dele mesmo, quer judicial, da mesma forma asseverada pela testemunha Joana; subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, diante da primariedade, confissão e colaboração do acusado com as investigações, com o reconhecimento do tráfico privilegiado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

Ricardo Alexander de Souza Gonçalves, policial militar, durante patrulhamento em região conhecida de tráfico de drogas avistou o acusado, o qual demonstrou

inquietação e nervosismo ao deparar-se com a presença da viatura; abordado, em poder do investigado foram apreendidas drogas; ao ser vez indagado a respeito da posse das cápsulas que continham cocaína, admitiu exercer o tráfico e produção naquele local, indicando que o restante dos entorpecentes estaria dentro do imóvel em frente ao qual se situava; o acusado, após anuir ao ingresso na residência, indicou o local das outras drogas, em cima da mesa da cozinha, além de balança, máquina de cartão de crédito, dinheiro, frasco de cloreto de sódio e mais um simulacro de pistola e quatro munições de revólver calibre 38;

Seguiu o policial Ricardo, o acusado teria afirmado não possuir arma de fogo e que usava do simulacro para a prática de roubos, acompanhado de outros comparsas; o acusado, continuou, na ocasião exibiu no celular imagens extraídas de câmeras de segurança de um suposto roubo, com o uso de arma de fogo, em um restaurante no qual teria concorrido à subtração de uma caminhonete Hilux e, sobre este fato, apontou quem seriam seus comparsas, dois dos quais, empreendidas diligências, foram detidos sob a confissão de seus envolvimento no referido roubo.

Eduardo Henrique Ribeiro, também policial militar, a par das informações prestadas pelo seu companheiro de corporação acima inquirido, reforçou ter o acusado admitido que, além da posse de drogas para a venda, também executava a produção e então autorizou o ingresso na residência, dentro da qual foram localizadas mais drogas, insumos e demais petrechos como balança, além do simulacro e das munições de calibre 38; complementou que o acusado também admitiu a prática de roubos.

Joana D'arc da Silva disse conhecer o acusado desde o nascimento, ser vizinha aos fundos da residência dele, que o acusado tem emprego fixo em firma de pinturas Polimoura e congrega com ele na mesma igreja; mencionou ter visualizado o acusado sendo abordado, os policiais chutando a porta da casa (usando de força física para estourar o portão) e nela ingressaram; não ouviu, por estar mais distante, a conversa dos policiais com o acusado; desconhece de fatos desabonadores do acusado; informou que o acusado residia há pouco tempo no local na companhia da namorada.

Daiane Aparecida da Silva expôs conhecer o acusado desde quando ele era criança, por frequentarem o culto de jovens juntos na mesma igreja; mencionou que o acusado vinha morando com a namorada; declarou ter se surpreendido quando o acusado foi preso, por ser ele bom, sem nunca mexer com coisa errada; disse não ter visto a abordagem policial na ocasião dos fatos.

Interrogado, o acusado esclareceu morar na companhia da namorada na rua Santos, nº 467, Vila Carvalho, ser frequentador de igreja com seus familiares, trabalhava na Polimoura com atividade de pintura em pó, da qual foi desligado e ficou sem meios financeiros de sustentar a namorada, vivendo sob o auxílio de sua genitora; diante disso, explicou, comprou no dia 9 de fevereiro (quarta-feira), por um mil e duzentos reais (obtidos com a genitora), as drogas para "tentar fazer um dinheiro a mais" e no dia 11, aproximadamente às 8h da manhã, sofreu revista dos policiais - não carregava nenhum entorpecente consigo na ocasião - e, mesmo sem dar autorização, a equipe violou sua residência e apreendeu as drogas, com o caderno de anotações a elas relacionados, bem como o simulacro e as munições, para as quais não tinha autorização de posse (guardava há cinco dias para um amigo).

O acusado afirmou que o aparelho celular Samsung estava dentro do imóvel; mencionou que a carteira de habilitação de Manoela foi deixada, um dia antes dos fatos, na sua casa por um amigo que pretendia cadastrar um chip de celular em nome dela; sobre a máquina de cartão "Moderninha" disse tê-la comprado, por trinta reais, para vendê-la à sua prima proprietária de uma sorveteria; confirmou ser seu o valor de cento e setenta e dois reais em dinheiro resultante da venda dos entorpecentes; corroborou que as duas pessoas relacionadas às imagens exibidas pelo celular foram conduzidas pelos policiais até à delegacia; explicou ter mantido via whatsapp as conversas extraídas do celular e que expressões como "chefe, rei" significariam gírias utilizadas com amigos.

O cenário formado ao término da instrução processual possibilitou demonstrar o enredo fático, com as implicações criminais, narradas na peça acusatória.

A motivação que conduziu à abordagem do acusado, por força de atitude suspeita visualizada, não traduz eventual ilegitimidade.

A equipe deparou-se com a exata situação de o acusado, ao notar a presença da

viatura, aparentar inquietação e nervosismo em região conhecida pelo tráfico de drogas.

O artigo 240 e seu parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, estabelecem que “a busca será domiciliar ou pessoal” e “proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

O artigo 244, do mesmo diploma legal, prevê que “A busca pessoal independe de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Nessa senda, Guilherme de Souza Nucci alerta pontificando que “não teria mesmo cabimento exigir, para a realização de uma busca pessoal, ordem judicial, visto que a urgência que a situação requer não comporta esse tipo de providência”, ilustrando que “se uma pessoa suspeita de trazer consigo a arma utilizada para a prática de um crime está passando diante de um policial, seria impossível que ele conseguisse, a tempo, um mandado para efetivar a diligência” (Código de Processo Penal Comentado. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 667).

Os depoimentos prestados pelos policiais revelaram-se precisos, insuspeitos, forneceram relatos complementares e merecem crédito, com citações oportunas das ementas que seguem:

“Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante.” (TJ-SP; APL 0000044-

47.2016.8.26.0070; Ac. 10925727; Batatais; Oitava Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ely Amioka; Julg. 26/10/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3120);

“Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios ou elementos outros de prova que lhes retire, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção.” (TJ-SP; APL 0000750-

41.2016.8.26.0616; Ac. 10942557; Mogi das Cruzes; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 31/10/2017; DJESP 10/11/2017; Pág. 2743);

“Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são perfeitamente válidos como prova. Os atos praticados pelos policiais, além de dotados de fé pública e possuírem presunção iuris tantum de veracidade, retratam as circunstâncias da prisão. Tais depoimentos somente não seriam válidos se ficasse demonstrado algum interesse pessoal ou qualquer arbitrariedade que pudesse comprometer a veracidade deles, o que não se verificou no caso concreto

(Precedentes do STJ; STF; e desta Corte).” (TRF 02ª R.; Acr 0807483-30.2010.4.02.5101; Primeira Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Abel Gomes; Julg. 28/06/2017; DEJF 14/07/2017).

A pretensão nulidade decorrente da suposta violação de domicílio não encontra amparo no acervo de provas reunidos, sobretudo porque os policiais, desde o início (págs. 4/6), como também em juízo, frisaram que o acusado, com o qual ainda do lado de fora da residência foi apreendida a quantidade de vinte e seis cápsulas contendo cocaína, logo em seguida, além de admitir o exercício da traficância, também deu conhecimento que, dentro do imóvel, haveria o restante das drogas, para onde então, sob sua autorização e acompanhamento, quicá à distância, ingressaram e, enfim, apreenderam tanto os entorpecentes como demais outros petrechos, a incluir o simulacro e as munições.

Muito embora a testemunha Joana, vizinha de fundo do acusado, tenha trazido a leitura de violação do domicílio não autorizada pelo acusado, ao mesmo tempo também

afirmou que estava distante e não foi capaz de ouvir as conversas travadas entre o acusado com os policiais.

Mesmo que tomado em parâmetro o precedente STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Informativo 687), o relator teria proposto a fixação do prazo de um ano para o aparelhamento dos órgãos de segurança pública na captação das operações/diligências por áudio e vídeo, mas se trata de providência que, mais adiante, foi revista e anulada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo principais trechos trazidos abaixo extraídos do voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1342077, Julgamento: 02/12/2021, Publicação: 06/12/2021: "Ocorre, entretanto, que a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, não só transformando o presente habeas corpus individual em um habeas corpus coletivo, como também estabelecendo requisitos constitucionalmente inexistentes e determinando em abstrato e com efeitos vinculantes e erga omnes a todos os órgãos da administração de segurança pública do País - estaduais, distrital e federal - verdadeira obrigação de fazer inexistente na Constituição Federal e na legislação [...]

Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Superior Tribunal de Justiça, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.

A decisão, portanto, não merece prosperar"

Reputa-se hígida, portanto, a diligência, mesmo porque não há contraprova da não autorização expressa à entrada dos policiais na residência.

Ainda a isso é necessário acrescentar que os crimes em debate, seja o de tráfico de drogas como o de posse irregular de munição, enquadram-se, ambos, como crimes permanentes, em função dos quais, somados a todos os elementos trazidos, torna dispensável a expedição de mandado de busca domiciliar, a exemplo dos arestos do Superior Tribunal de Justiça a seguir colacionados:

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FORO DE USO RESTRITO (ARTIGOS 12 E 16 DA LEI 10.826/2003). ALEGADA NULIDADE DA PROVA OBTIDA COM A BUSCA E APREENSÃO REALIZADA. MANDADO REFERENTE À RESIDÊNCIA DE PESSOA DIVERSA DO PACIENTE. DOCUMENTO QUE JÁ ESTARIA VENCIDO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EIVA NÃO CARACTERIZADA.

1. Apesar de o mandado de busca e apreensão se referir somente à residência de pessoa conhecida como Germano de Souza, e haver sido expedido no dia 23.8.2011, com prazo de validade de 20 (vinte) dias, tendo sido cumprido em 16.9.2011, tais fatos são insuficientes para macular a prova obtida por ocasião do ingresso dos policiais na residência do paciente, que foi preso em flagrante pela prática de crimes de natureza permanente, quais sejam, os previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/2003. 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas (Doutrina e jurisprudência)" (STJ - 5ª Turma - HC 244016/ES - Ministro JORGE MUSSI - DJE - 05.11.2012)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. REGIME PRISIONAL GRAVOSO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. [...] 5. Agravo regimental desprovido." (STJ; AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Publicação: 10/05/2017).

Tráfico de drogas

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou nos exames de constatação

provisória de págs. 55/58 e no exame químico-toxicológico acostado a págs. 200/203 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) alcaloide extraído do vegetal "Erythroxylum coca", distribuída em 155,38g acondicionadas em 01 invólucro de plástico de cor branca, 60,05g acondicionada em 02 invólucros de plástico, sendo um na cor branca e outro na cor verde, 4,39g, na forma de crack, acondicionadas em 01 invólucro de plástico de cor verde, 12,18g acondicionadas em 26 microtubos de plástico, do tipo "eppendorf", de cor preta, bem como a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, L (maconha), repartida na porção de 127,78g acondicionada em 01 invólucro de plástico de cor branca, contendo 05 invólucros plásticos aderentes com fragmentos vegetais, e fragmentos vegetais desprovidos de invólucros individuais, 376,26g acondicionada em 01 invólucro de plástico incolor envolto por fita adesiva parda, além de 887 mini flaconetes denominados "eppendorfs", balança digital, 5 flaconetes contendo cloreto de sódio, conforme laudo pericial de págs. 209/212, e a quantia de R\$172,00, segundo depósito de pág. 165.

A configuração da traficância seguiu mais ainda complementada com a apreensão das anotações com conteúdo típico atrelado ao exercício da venda de drogas (págs. 36/52), assim como da agenda (págs. 109/140), tanto umas como outra trazendo esclarecidas referências a expressões como "pó", "maconha", "paranga", "pedra", "lucro", quais quantidades foram pagas, quantas faltam a ser quitadas, quais pessoas já levaram, cálculos, a exemplo aos de págs. 138 e 139 de quanto "gui" ainda faltaria entregar de dinheiro.

Para a consumação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

"Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792) ; "No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de "trazer consigo" e "guardar", não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda." (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844); "Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela quantidade, variedade, natureza e forma de acondicionamento, divididos em porções individuais, pela detalhada informação apócrifa, cuja veracidade foi constatada pelos agentes públicos, elementos suficientes à procedência da pretensão punitiva, não remanescendo quaisquer dúvidas, quanto ao destino a terceiros, salientando-se que eventual condição de usuária não seria impeditiva da realização concomitante do comércio clandestino, o que arreda a tese desclassificatória ventilada em autodefesa." (TJ-SP; APL 0001364-89.2016.8.26.0537; Ac. 10947155; São Bernardo do Campo; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Eduardo Abdalla; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2794).

Destarte, o conjunto de circunstâncias acima alinhadas, somado à confissão do

acusado, confirmam a caracterização do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Posse irregular de munições

A materialidade do delito de posse irregular das munições encontra-se consubstanciada no boletim de ocorrência (págs. 9/15), no auto de exibição/apreensão (págs. 16/18) e no laudo pericial (págs. 282/285).

Consiste em crime denominado pela doutrina como de perigo abstrato e de mera conduta; assim, para sua consumação, basta a realização de uma das ações nucleares do tipo penal em tela – possuir ou manter sob sua guarda – sem a autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...] 5. A jurisprudência do STF é no sentido de que “os delitos de posse e de porte ilegal de arma de fogo tutelam a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante a comprovação da potencialidade lesiva do armamento, por tratar-se de crime de perigo abstrato” (ARE 1.101.003, Rel. Min. Luiz Fux) [...]

7. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1122678 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018).

"Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que os delitos de porte ou posse de arma de fogo, acessório ou munição, possuem natureza de crime de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico a segurança coletiva, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial" (STJ, HC 366.292/SE, Ministro Relator JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 27/6/2017).

Ainda que assim não fosse, o laudo pericial atestou que os quatro cartuchos foram “disparados mostrando-se eficazes” (págs. 282/285).

À hipótese não incide o princípio da insignificância, pois, na linha da inteligência do Supremo Tribunal Federal, “[...] Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes. 5.

Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, HC 206977 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022).

Demonstrado à saciedade que o agente tinha a posse irregular de munições, adequada a modelagem de sua conduta ao artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

Passo à dosagem das penas:

Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavoráveis as consequências do crime, ante a expressiva quantidade e variedade de drogas, segundo listagem detida constante do laudo de constatação provisória de págs. 55/58 e do exame químico-toxicológico de págs. 200/203, circunstância indicativa das consequências nefastas em potencialmente atingir maior número de pessoas quando da distribuição das drogas, lembrando que a pena para o crime em análise varia de cinco a quinze anos de reclusão, de sorte a justificar fixação da pena-base em seis anos e seis meses de reclusão e pagamento de seiscentos e cinquenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

Importante lembrar que a dosimetria da pena não guarda critérios rígidos e puramente objetivos, sujeitando-se à discricionariedade vinculada às balizas do tipo penal aplicável à espécie, em atenção à chamada teoria das margens.

Essa inteligência é retratada nos seguintes arestos do Supremo Tribunal Federal:

[...] 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena [...]” (HC 141487, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2019 PUBLIC 27-02-2019) e do Superior Tribunal de Justiça: “Rememoro que o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado. Desse modo, as

circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nortearão o sentenciante na escolha do aumento de cada circunstância judicial desfavorável” (STJ, AgRg no HC 558.538/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

II. Dentre as circunstâncias legais, presentes a confissão, prestada de acordo com a Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça, e a menoridade relativa (nascido em 27/12/2003), a reduzir, para cada uma, três meses de reclusão e vinte e cinco dias-multa, perfazendo o subtotal de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa;

III. Não há causas especiais de aumento, tampouco de diminuição, ressalvando-se a inviabilidade de reconhecimento do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, porquanto o acervo probatório demonstrou dedicação sensível do acusado em atividades criminosas, tais quais se nota das anotações de págs. 36/52 e a agenda de págs. 109/140 as quais, muito embora refutado em interrogatório ser de sua grafia, o acusado as armazenava em típica situação de parceria com outros infratores, ao mencionar, por exemplo, que o simulacro e as munições guardava em favor de um amigo, confirmou que as duas pessoas envolvidas no assalto retratado nas imagens exibidas em seu celular foram conduzidas pela equipe policial à delegacia, o que induz também estar vinculado ao assalto da Hilux no restaurante mencionado pelos militares.

Ademais, relevante observar que, igualmente admitido no interrogatório em juízo, manteve conversas via aplicativo de mensagem instantânea whatsapp com amigos, cujas telas de pág. 228 ilustram conversas com “Gui” sob a exortação de potencialmente integrarem o PCC no eixo de atuação 016, à pág. 232 “Bocão” envia a mensagem ao acusado com os dizeres “vou aí pegar 5 real de maconha” e à pág. 236 depara-se com imagens “contendo arma de fogo e material semelhante a 'crack' em momento de pesagem”.

Tais elementos são aptos a afastar o redutor do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06 pelo descumprimento do requisito exigido em lei consistente na ausência de dedicação do acusado a atividades criminosas, devendo ser considerado que “exigir a existência de prévio cometimento de crime e de prévia imposição de pena para fins de justificar o afastamento do redutor em questão acaba, em última análise, esvaziando o próprio conceito de dedicação a atividades criminosas. Isso porque, se houver trânsito em julgado de condenação por crime praticado anteriormente, então essa condenação anterior já se enquadra ou no conceito de maus antecedentes ou no de reincidência. Assim, considerando que não há palavras inúteis na lei, por certo que o legislador quis abarcar situação diversa ao prever a impossibilidade de concessão do benefício àqueles indivíduos que se dedicam a atividades criminosas” (STJ. 3ª Turma. EREsp 1.916.596-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. Laurita Vaz, julgado em 08/09/2021 - Info 712).

Torno definitivo o quantum de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a hediondez do delito, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme anotado no item “I”, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento. Insuficiente o critério objetivo temporal para progressão para o regime semiaberto (artigo 387, parágrafo 2º, do Código Processo Penal), iniciará o cumprimento no regime original.

artigo 12, da Lei 10.826/2003

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavoráveis as circunstâncias do crime, eis que a apreensão das quatro munições não foram isoladas e sim acompanhadas de simulacro para o exercício, conforme relatado pelos policiais e confirmado em interrogatório pelo próprio acusado, para a prática de assaltos e comparsaria com mais outras duas pessoas, ao menos para aquele roubo relacionado às imagens do celular, a se conjugar como negativa, outrossim, a personalidade do agente, assim definida como as externalidades de “seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).” STJ. 3ª Seção. EAREsp 1.311.636-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/04/2019

(Info 647), para a qual “a valoração da personalidade do agente na dosimetria da pena envolve o “sentir do julgador”, que tem contato com as provas, com os meandros do processo. Justamente por isso, não é necessária a realização de qualquer estudo técnico. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018, repisadas aqui também as reflexões lançadas no tópico acima dedicado ao afastamento da benesse do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, a justificar o acréscimo de oito meses de detenção e oito dias-multa.

Relembra a variação de pena privativa de liberdade entre um e três anos de detenção, cumpre estabelecer a pena-base em um ano e oito meses de detenção e dezoito dias-multa, no valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presentes a confissão e a menoridade relativa (nascido em 27/12/2003), a reduzir, para cada uma, dois meses de detenção e um dia-multa, perfazendo o subtotal de um ano e quatro meses de detenção e dezesseis dias-multa;

III. Ausentes circunstâncias legais, tampouco causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Torno definitivo o quantum de um ano e quatro meses de detenção e dezesseis dias-multa, no valor mínimo unitário;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, será o da modalidade aberto, sujeito às condições previstas nos incisos I a IV, do artigo 115, da Lei de Execução Penal, revelando-se inviável cogitar-se em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (artigo 44, inciso III, do Código Penal), eis que “A pena-base foi estipulada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, razão pela qual inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal.” (STJ, AgRg no HC 368.734/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), bem como por força da vedação do parágrafo 1º, do artigo 69, do Código Penal.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência condeno KAUAN PATRICK DE OLIVEIRA SANTANA, qualificado nos autos, à pena de seis anos de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de seiscentos dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; outrossim, condeno-o à pena de um ano e quatro meses de detenção (regime aberto, sujeito às condições previstas nos incisos I a IV, do artigo 115, da Lei de Execução Penal) e ao pagamento de onze dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 12, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03).

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas (mantido o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça deliberado no item “III” de pág. 244, pois preservado o mesmo contexto fático à época tomado em valoração como razão de decidir).

Em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como da manutenção de motivos que deram ensejo à prisão cautelar (págs. 80/84), sobretudo agora por estar emoldurada uma das condenações ao caput, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ou seja, revestida de natureza hedionda, aqui renovada a contemporaneidade da segregação também para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto com o elevado montante no somatório das penas e regime prisional impostos a perspectiva de evasão do distrito da culpa se potencializa; portanto, não poderá apelar em liberdade, anotando-se inexistir óbice a essa condicionante (verbete nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra recolhido. Na hipótese de interposição de recursos, extraia-se guia de execução provisória.

Comunique-se a autoridade policial a autorização de remessa das munições apreendidas ao Exército para destruição, a teor do artigo 25, da Lei nº 10.826/03.

A origem do numerário encontrado em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito desenvolvido, conforme por ele mesmo confessado em juízo ser o dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Diante disso, decreto o perdimento da quantia de

R\$172,00 depositada à pág. 165, em favor da União.
Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15,
inciso III, da Constituição Federal).
Publicada em audiência.
Ribeirão Preto, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA